

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3340/2550

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นายไชยา ทับประเทือง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 157

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 59

การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทโดยนอกจากมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตาม ป.อ. มาตรา 157 แล้วยังมีความผิดต่อ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ มาตรา 59 ซึ่งบัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่ต่ำกว่าสี่ปีและไม่เกินแปดปีด้วย อันเป็นมาตรการที่มุ่งจะจำกัดสิทธิของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งซึ่งกระทำหน้าที่โดยทุจริตไม่ใช่โทษตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อศาลลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ตาม ป.อ. มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตาม ป.อ. มาตรา 90 ศาลก็ต้องสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ด้วย ตามที่กฎหมายบัญญัติบังคับไว้โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ มิฉะนั้นจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2542 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งเจ็ดและนายสุชาติ

จำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6100/2542 ของศาลชั้นต้น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการตรวจคะแนน และกรรมการตรวจคะแนนไปพลางก่อนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 15 เขตเลือกตั้งที่ 3 กับพวกอีกหลายคนซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันลงเครื่องหมายกากบาทในช่องเครื่องหมายประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 2 ในบัตรเลือกตั้ง จำนวน 100 ใบ นำไปวางไว้ที่โต๊ะกรรมการตรวจคะแนนเพื่อเตรียมนำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวหย่อนลงไปในห้องบัตรเลือกตั้ง ร่วมกันลงเครื่องหมายกากบาทในช่องเครื่องหมายประจำตัวผู้สมัครหมายเลขใดไม่ปรากฏชัดในบัตรเลือกตั้ง จำนวน 303 ใบ หย่อนลงไปในห้องบัตรเลือกตั้ง และร่วมกันจดหมายเลขของบัตรประจำตัวประชาชนผู้เลือกตั้งลงในบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งจำนวน 409 หมายเลข ก่อนที่จะเปิดการเลือกตั้งเพื่อให้เข้าใจว่ามีผู้เลือกตั้งมาใช้สิทธิแล้วจำนวน 409 คน เมื่อถึงเวลาลงคะแนนจะได้เปิดการลงคะแนนโดยไม่เปิดห้องบัตรเลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่าเป็นห้องเปล่าแล้วปิดห้องบัตรเลือกตั้ง ไม่ประกาศว่าเริ่มลงคะแนนได้แล้ว การกระทำของจำเลยทั้งเจ็ดกับพวกเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เทศบาลตำบลบางปู นายอำเภอเมืองสมุทรปราการและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครหมายเลข 2 ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู จงใจทำรายงานการเลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือกระทำการโดยเจตนาขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับอันเกี่ยวแก่การเลือกตั้ง ลงเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งซึ่งมิใช่ของตนโดยเจตนาทุจริต ลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น ทอดบัตรและพยายามทอดบัตรมากกว่าบัตรหนึ่งหรือมากกว่าครั้งหนึ่งในการลงคะแนนเลือกตั้ง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 157 พระราช

บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 4, 29, 32, 33, 43, 45, 47, 59, 60, 71, 72 และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจำเลยทั้งเจ็ดตามกฎหมาย

จำเลยทั้งเจ็ดให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 59, 60, 71, 72 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 มีกำหนดคนละ 4 ปี ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 7

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 59 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ขอลาและคำขออื่นให้ยก ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 6 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า ศาลต้องสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่ 1 และที่ 3 หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทโดยนอกจากมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 แล้ว ยังมี ความผิดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 59 ซึ่งบัญญัติให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่ต่ำกว่าสี่ปีและไม่เกินแปดปีด้วย อันเป็นมาตรการที่มุ่งจะจำกัดสิทธิของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งซึ่งกระทำหน้าที่โดยทุจริตไม่ใช่โทษตามกฎหมายดังนั้น เมื่อศาลลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ศาลก็ต้องสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติบังคับไว้โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ มิฉะนั้นจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ได้มีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 และให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้แทน ซึ่งมาตรา 75 และ 78 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 บัญญัติให้การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นความผิดและมีบทลงโทษตามมาตรา 118 และ 126 ที่หนักกว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 59 ไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมบังคับ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่ 1 และที่ 3 มีกำหนด
คนละ 4 ปีด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(วิเชียร มงคล-กิตติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์-เอกชัย ชินณพวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาในคดีนี้วางหลักกฎหมายไว้ว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ใช่โทษตามกฎหมาย ปัญหาที่ต้องถามต่อไปก็คือว่า เมื่อไม่ใช่โทษตามกฎหมายแล้วการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นอะไรในสายตาของกฎหมาย และเมื่อไม่ใช่โทษตามกฎหมายแล้วในการใช้ดุลพินิจกำหนดระยะเวลาในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งศาลจะใช้หลักอะไรมา กำหนดระยะเวลาดังกล่าว (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ มาตรา 59 บัญญัติว่าให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ปี และไม่เกิน 8 ปี) ตามกฎหมายเยอรมัน ระบบผลในทางกฎหมายของกฎหมายอาญาได้แบ่งออกเป็นสองประเภทกล่าวคือ ในประเภทแรก ผลในทางกฎหมายของกฎหมายอาญาโดยแท้ก็คือโทษในทางอาญา (die Strafe) โทษในทางอาญาหมายถึงการที่ต้องได้รับผลร้ายจากรัฐ (Staatliche Uebelszufuegung) และรวมทั้งการที่การกระทำความผิดดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับในทางจริยศาสตร์และได้รับการตำหนิ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้โทษในทางอาญาแตกต่างจากโทษปรับในทางปกครองและมาตรการในการลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ การจะลงโทษในทางอาญาได้ก็ต่อเมื่อมีความน่าตำหนิ ในการกำหนดโทษ

ในทางอาญาจึงต้องเป็นไปตามหลักความน่าตำหนิตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 46 (1) ประโยคที่หนึ่ง ภารกิจในการป้องกันทั่วไปของโทษในทางอาญาจะต้องทำให้ผู้อื่นไม่กระทำความผิด นอกจากนี้โทษในทางอาญาจะต้องมีผลในทางป้องกันต่อผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลไป ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้อีกครั้ง กฎหมายอาญามีรูปแบบของโทษอาญาอยู่สองประเภท กล่าวคือ โทษจำคุกและโทษปรับ ซึ่งเป็นโทษอาญาหลัก นอกจากโทษอาญาหลักก็มีโทษอาญาข้างเคียง ซึ่งก็คือการห้ามขับชี่ยานพาหนะตามมาตรา 44 ซึ่งสามารถที่จะลงโทษการห้ามขับยานพาหนะได้ก็ต่อเมื่อได้มีการลงโทษอาญาหลักด้วย รูปแบบที่สองของมาตรการบังคับในทางอาญาก็คือวิธีการเพื่อความปลอดภัยซึ่งตามมาตรา 12 ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติประเภทของวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่แตกต่างกันเอาไว้ เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตขับชี่ยานพาหนะ หรือการห้ามประกอบอาชีพ เป็นต้น ลักษณะเฉพาะของวิธีการเพื่อความปลอดภัยก็คือ มีไว้เพื่อคุ้มครองสังคมและคุ้มครองตัวผู้กระทำความผิดเอง ความแตกต่างในทางหลักการระหว่างโทษทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัยก็คือ โทษทางอาญาจะต้องเป็นไปตามหลักความน่าตำหนิในขณะที่วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักความน่าตำหนิ และพิจารณาเฉพาะในส่วนของการเป็นอันตรายของตัวผู้กระทำความผิดในฐานะที่เป็นมาตรการในการป้องกัน (vgl. Nelles, Statusfolgen als, Nebenfolgen "einer Straftat (Paragraph 45 StGB), JZ 1991, หน้า 17-18) การปฏิรูปกฎหมายอาญาได้ยกเลิกการเพิกถอนสิทธิในเกียรติยศของการเป็นพลเมือง (die Aberkennung der buergerlichen Ehrenrechte) ตามมาตรา 45 คงกำหนดไว้เฉพาะในกรณีของการสูญเสียสิทธิในการเข้ารับราชการ สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ถือเป็นผลที่เกิดขึ้นแก่สถานะของบุคคลอันเป็นผลมาจากการถูกลงโทษในทางอาญาโดยศาลอาญาฝ่ายนิติบัญญัติได้ตั้งชื่อของผลที่เกิดขึ้นแก่สถานะของบุคคลดัง

กล่าว (Statusfolgen) ว่าเป็นผลข้างเคียง (Nebenfolgen) เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่
เป็นกรณีของโทษอาญาข้างเคียง (Nebenstrafen) (ซึ่งตามร่างประมวลกฎหมาย
อาญาในปี 1962 มาตรา 56 ได้กำหนดให้การสูญเสียสิทธิในการเข้ารับราชการ การ
สูญเสียสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้ง และการสูญเสียสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งเป็นโทษอาญาข้างเคียง) เช่นเดียวกับกรณีของการห้ามขับขียานพาหนะตาม
มาตรา 44 และในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นกรณีของวิธีการเพื่อความปลอดภัยตาม
มาตรา 61 เป็นต้นไป หากแต่เป็นมาตรการบังคับที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง
(Sanktionen eigener Art) ที่มีส่วนสัมพันธ์อยู่กับการพิพากษาลงโทษในทางอาญาที่
เป็นผลมาจากบทบัญญัติของกฎหมายหรืออาจจะมีส่วนสัมพันธ์กับคำพิพากษาของ
ศาล (vgl. Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts : Allgemeiner
Teil, 4 Auflage, (Duncker & Humblot : Berlin, 1988), บทที่ 75, หน้า 712) ตาม
กฎหมายเยอรมัน ได้บัญญัติกรณีของการสูญเสียสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นสอง
กรณี กล่าวคือ ตามมาตรา 45 (1) การสูญเสียสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งเป็นไป
โดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมาย ในกรณีของการต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกไม่
น้อยกว่า 1 ปี ในความผิดอาญาร้ายแรง ส่วนกรณีที่สองเป็นไปตามมาตรา 45 (2) ที่
ปล่อยให้เป็นผู้พิพากษาที่จะเพิกถอนสิทธิที่จะรับสมัครเลือกตั้ง เฉพาะ
เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษให้ศาลมีดุลพินิจดังกล่าวเท่านั้น เช่น ตามมาตรา
92a, 101, 108c, 109i เป็นต้น (vgl. Nelles, JZ1991, 17) หากพิจารณาจากหลัก
กฎหมายเยอรมันข้างต้น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายไทยก็น่าที่จะเป็น
ผลข้างเคียง (Nebenfolgen) ของการกระทำความผิดอาญา ตามกฎหมายไทย การ
สูญเสียสิทธิเลือกตั้งเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ แต่จะต่างจาก
กฎหมายเยอรมัน ตามมาตรา 45 (2) ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ตรงที่ศาลไม่
อาจมีดุลพินิจไม่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาว่าเมื่อศาลถูกบังคับให้
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้ว ศาลจะใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดระยะเวลาเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง ผู้เขียนเห็นว่าสามารถนำหลักในเรื่องการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษมาปรับใช้ได้ แม้ว่าการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะไม่ใช้โทษทางอาญาก็ตาม Prof. Jescheck ให้ความเห็นไว้ว่าต้องนำหลักในเรื่องการป้องกันทั่วไปและการป้องกันพิเศษมาปรับใช้กับกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นในการที่ต้องกันผู้กระทำผิดไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐและการที่จะทำให้บุคคลในสังคมมีความเคารพต่อกฎหมายโดยที่ในกรณีนี้ผู้พิพากษาไม่จำเป็นต้องยึดหลักความน่าตำหนิ (Das Schuldprinzip) โดยเคร่งครัดนัก (Jescheck, Lehrbuch Des Strafrechts : Allgemeiner Teil, 4 Auflage, 1988 บทที่ 75, หน้า 713 - 714) ดังนั้น หากผู้พิพากษาเห็นว่าการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 4 ปี จะได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดกล่าวคือเป็นไปตามหลักความน่าตำหนิ แต่ถ้าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 6 ปี จะทำให้การป้องกันทั่วไปและการป้องกันพิเศษได้ผลยิ่งกว่าก็สามารถที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 6 ปีได้แม้ว่าจะขัดกับหลักความน่าตำหนิก็ตาม (รายละเอียดของหลักความน่าตำหนิการป้องกันทั่วไปและการป้องกันพิเศษดูได้จากสุทธิธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ การใช้ดุลพินิจกำหนดโทษทางอาญา, ในหนังสือการดำเนินความยุติธรรมตามรอยพระยุคลบาท, หน้า 247 - 266) ปัญหาจะเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในกรณีที่หากการลงโทษจำคุกเพียง 3 ปี ซึ่งเป็นอัตราโทษที่ต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะเป็นการเพียงพอที่จะกันไม่ให้ผู้กระทำผิดกระทำผิดอีกและไม่ได้ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่เคารพกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ แม้ว่าสั่งจำคุก 3 ปี ก็ไม่เป็นการขัดต่อหลักการป้องกันพิเศษและหลักการป้องกันทั่วไปแล้ว ปัญหาว่าศาลสามารถสั่งจำคุกเพียง 3 ปี ได้หรือไม่ แม้กฎหมายจะกำหนดโทษขั้นต่ำไว้ 4 ปี ในกรณีดังกล่าว Prof. Roxin เห็นว่า สามารถทำได้ (รายละเอียดความเห็นของ Prof. Roxin ดูจาก สุทธิธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์, อ้างแล้ว, หน้า 259 - 263 หัวข้อ 4.1.5 ทฤษฎีแบบผสมผสานที่เป็นการป้องกัน) สุทธิธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์